MPF 557431 – DEN 724975 "s/Nombre (alias FUNCIONARIO PUBLICO) S/Art. 249"

1.- Llega el presente caso a conocimiento del suscripto en función del pedido de revisión de archivo presentado por el Sr. Nicolás H. Kosciuk.

Las actuaciones se iniciaron el 5 de marzo de 2021 a raíz de la denuncia formulada por el nombrado, mediante correo electrónico, ante la OCRD de este MPF. En tal oportunidad manifestó: *"(...) me gustaria denuncia[r] por encubrimiento al Fiscal ADRIAN PATRICIO GRASSI de la UIT Norte en relacio?n a la denuncia DEN00716161, en la cual denuncie por encubrimiento al Fiscal Rozas en la denuncia de falso testimonio de un me?dico. El Fiscal, en lugar de investigar, hace referencia a otra denuncia por encubrimiento referido a un abandono de persona. Con lo que no me parece valido utilizar archivos de otras denuncias para archivar nuevas denuncias cuando lo denunciado es completamente distinto, aunque relacionado. Es decir, el Fiscal invento un testigo falso, pero pese a mis incontables denuncias, nadie [h]a querido investigar a ese testigo falso. Tambien hace referencia a una denuncia de la que aun no recibi ninguna notificacion, la 713875, en la que se denuncio una historia clinica incompleta. que tampoco veo que relacion guarda con la denuncia 716161. Nuevamente relaciona denuncias aisladas. Por otra parte, tambien tengo que denunciar que pese a haber solicitado la revision, mi pedido fue ignorado, ni aceptado ni rechazado, ignorado, puesto que no recibi ninguna comunicacio?n".*

Ese mismo día, el denunciante envió un correo electrónico al personal de la UIT de la UFE que rezaba: *" Hola, este mensaje es simbólico, solo estoy recolectando fiscales para mi listado de encubridores, ni se cuantos tengo ya que fueron incapaces de: a) darse cuenta que una historia clínica estaba incompleta, b) nadie investigo a Lizardo, porque fue un invento de otro Fiscal. Es como con el caso de Ursula, 18 denuncias y nada".*

El 9 de marzo de 2021 , el Sr. Fiscal Coordinador de la UIT de la UFE dispuso el archivo del caso en los términos del art. 211, inc. "a" del CPP. Para adoptar dicha decisión sostuvo: *"(...) el*

Notificado de dicho temperamento el 11 de marzo de este año, el Sr. Kosciuk peticionó, al día siguiente, su revisión. En dicha ocasión refirió: *" Pido la revision, puesto que nunca se me notifico sobre la aceptacion de la revision, ni se me envio la notificacion de esa resolucion, resulta sorprendente como un Fiscal puede no investigar y se lo encubre. A ver si ponen alguien a investigar lo que no investigo el denunciado. Gracias".* Seguidamente, envió dos correos electrónicos en los que manifestó: *"Sigo pidiendo revision, agrego una copia porque despues pasan cosas raras. Asi que un Fiscal de Camara convalidó que un Fiscal no*

investigue? Necesito el nombre de ese Fiscal de Camara para denunciarlo tambien, gracias" y *" Hola, ¿me podrian pasar el PDF original? Lo necesito para mi pagina web, gracias!".*

Por último, el 15 de marzo del corriente año, el nombrado refirió: *" ¿Se puede dejar constancia de que el archivo del Fiscal de Camara al que hace mencion, no me fue notificado por ningun medio? ¿Hay alguien que me pueda explicar si el Fiscal puede decidir investigar por mas que haya una resolucion de archivo, o si hay un archivo ya automáticamente no se investiga nada? No se como hacer la denuncia para que se investigue por que el MPF elimino partes de una Historia Clinica, ni que averigue el paradero de una persona (un testigo inventado por el Fiscal Rozas), mientras no se investiguen esa[s] cosas, voy a seguir denunciando solo para ensartar a la mayor cantidad posible de Fiscales como encubridores".*

2 .- En primer lugar, debo señalar que la oposición fue presentada en tiempo y forma, por lo que corresponde proceder a su análisis.

En lo que hace al fondo de la cuestión traída a mi conocimiento, adelanto que comparto el temperamento adoptado por mi colega de grado y, por las razones que expondré a continuación, confirmaré el archivo dispuesto.

Primeramente, es dable destacar que el caso MPF 551317 (DEN 716161), caratulado *"S/Nombre S/Art. 249"* , tramitó ante la UIT de la UFN, donde el Dr. Adrián Patricio Grassi dispuso su archivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 211 inc. "e" del CPPCABA, el cual fue convalidado por el Fiscal de Cámara de la UFN, aunque en los términos del art. 211 inc. "d" del CPPCABA.

En tal oportunidad, el Dr. Grassi sostuvo: *" el presente caso tuvo inicio el pasado 5 de febrero a raíz de la denuncia efectuada por Nicolás Horacio Kosciuk, en la que pone de manifiesto su cuestionamiento hacia el proceder del Fiscal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de esta ciudad, en el marco de la denuncia que oportunamente efectuara contra el Hospital de Agudos Doctor Piñero, por el delito de abandono de persona en relación a su madre Margarita Kuchasski. Compulsado que fuera el sistema informático de la Fiscalía surge la existencia de la denuncia 713875 en el marco de la cual el denunciante hizo saber los mismos hechos aquí ventilados, habiéndose dispuesto el pasado 5 de febrero el archivo de las actuaciones por considerar que se trataba del mismo objeto procesal que el de las denuncias 641871, 632469 y 641877 (registradas bajo el MPF 462972), archivo que fuera convalidado por el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste. Ahora bien, analizadas las actuaciones debo señalar que la receptación del principio de oportunidad en la normativa procesal penal vigente en este ámbito territorial constituye una esencial herramienta para racionalizar y corregir disfunciones del sistema de persecución penal, al prever formalmente la disponibilidad del ejercicio de la acción por parte de los representantes de este Ministerio Público Fiscal. Es así que al advertir que en la presente se pretende denunciar el mismo hecho que ya fue resuelto en el marco de la denuncia 713875, entiendo que en este caso corresponde la aplicación de este principio" .*

A su turno, intervino el fiscal de cámara de la UFN a raíz del pedido de revisión

formulado por el denunciante, y en ese marco afirmó: *" considero que el archivo dispuesto se ajusta a las constancias del caso y al derecho vigente y por tal motivo será convalidado. En efecto, de la compulsa del sistema informático Kiwi se desprende que el MPF 546803 tuvo por objeto los mismos sucesos que los aquí denunciados, circunstancia que imposibilita el avance del presente legajo de conformidad al principio ne bis in ídem"* . En virtud de ello, decidió convalidar la decisión adoptada, *"modificando la causal por imposibilidad de promover la investigación (art. 211, inc. d. CPPCABA)"*.

Ahora bien, conforme fuera antes visto, el nombrado efectuó la presente denuncia, mediante la cual acusó al Dr. Adrián Patricio Grassi por su actuación en el caso recién mencionado.

Así pues habré de analizar si el fiscal Grassi incurrió en algún incumplimiento de sus deberes como funcionario público en el caso en que le tocó intervenir. Esto así, ciñéndome estrictamente a los dichos del denunciante, y en las muy especiales circunstancias del caso, en el que todo parecería indicar que, en definitiva, el Sr. Kosciuk no hace más que expresar su desacuerdo con relación a la decisión conclusiva adoptada por el denunciado.

Al respecto, conforme fuera adelantado, coincido con lo resuelto por el titular de la UIT de la UFE. En efecto, si bien corresponde ser extremadamente cauteloso a la hora de descartar la tipicidad de un hecho, el comportamiento atribuido al Dr. Grassi no reúne las condiciones necesarias para ser encuadrado en un tipo penal.

Cabe recordar que el art. 248 del CP sanciona al funcionario público que *"dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere"*, mientras que el art. 249 del CP reprime a aquel que *"ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio"*.

En relación con el bien jurídico cuya afectación pretende capturarse en esas figuras, se ha afirmado que es el *"normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado"* (D'ALESSIO, Andrés José (dir.) y DIVITO, Mauro A., (coord.), *Código Penal – Comentado y anotado*, La ley, Buenos Aires, 2004, p. 764), así como que se trata de infracciones que *"afectan la administración pública porque implican en sí mismas un arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las prescripciones constitucionales, de las leyes o deberes que la rigen"* (BUOMPADRE, Jorge E., comentario a los arts. 248/253 *ter* del CP en BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl (dir.), TERRAGNI, Marco A. (coord..) y DE LANGHE, Marcela (superv.), *Código Penal y normas complementarias – Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, p. 365).

Asimismo, los tipos previstos en los arts. 248 y 249 del CP podrían comprender —entre otras cosas y en lo que aquí nos interesa— la situación de un funcionario que ejerce una autoridad que no le fue concedida por la ley, o que sí le fue adjudicada, pero que es desarrollada

arbitrariamente, o bien que omite deliberadamente un deber a su cargo y que, paralelamente, cualquiera fuere el caso, lo hace con *dolo directo*, de manera tal que exhiba una voluntad dirigida a la violación de la ley y de las funciones a su cargo (véanse, al respecto, D'ALESSIO y DIVITO, ob. cit., pp. 796/804 y BUOMPADRE en BAIGÚN, ZAFFARONI, TERRAGNI y DE LANGHE, ob. cit., pp. 367/373).

Ahora bien, en el ámbito de la tramitación de los procesos judiciales, la eventual existencia de errores en la valoración de las circunstancias del caso o la interpretación de la ley aplicable por parte de los funcionarios actuantes —ya sea fiscales, defensores o jueces—, constituye una situación regularmente prevista por la legislación. De hecho, existen mecanismos expresamente previstos en las normas procesales para advertir y revertir esa clase de eventualidades. Entre ellos se encuentran, solo por mencionar algunos, los recursos (arts. 279 y sgtes., CPP), la nulidad de los actos procesales (arts. 77 y sgtes., CPP) y la facultad de los damnificados de solicitar la revisión de los archivos de las investigaciones (arts. 211 a 215, CPP).

Es claro, entonces, que no cualquier error en el ejercicio de funciones judiciales, defensivas o instructoras implica un incumplimiento encuadrable en los arts. 248 o 249 del CP. De otro modo, ello ocurriría cada vez que una resolución judicial es revocada, un acto procesal es anulado o un archivo es revertido por un magistrado. Es evidente que esta no pudo ser la intención del legislador al regular los mencionados tipos penales. Las figuras penales se refieren, en cambio, a situaciones excepcionales en las que, en rigor, no se trata de meros errores o equivocaciones, sino de actos dirigidos específicamente a la violación de la ley.

Teniendo en cuenta esos parámetros, podemos comenzar por descartar que el fiscal denunciado haya ejercido una facultad *no concedida por la ley*. El Código Procesal Penal de la CABA autoriza expresamente a los acusadores públicos a ordenar el archivo de las actuaciones en casos penales (art. 211 y ccdtes., CPP) y ello se condice con el diseño acusatorio del proceso penal local, en el que el ejercicio de la acción y la conducción de la investigación preliminar se encuentran a cargo del Ministerio Público Fiscal (arts. 13.3, CCABA y 4, CPP). Paralelamente, se trata de una prerrogativa considerablemente amplia, pues las razones por las cuales la ley procesal autoriza a un fiscal a clausurar una pesquisa son variadas y, en muchos casos, su pronunciamiento puede resultar definitivo respecto de la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de continuar impulsando la acción.

Además, la ley procesal no condiciona la *validez* del archivo del caso a la celebración de una entrevista con el denunciante o la producción de prueba, ya que, de hecho, autoriza el archivo *"de la denuncia"* misma (art. 211, CPP). En otras palabras, al margen de la excepcionalidad de las situaciones en las que toda la información necesaria para resolver emerge de ese acto inicial, la ley procesal no prohíbe el archivo de un caso en esas condiciones.

Entonces, dado que el archivo de una denuncia es una posibilidad específicamente prevista por la ley, cabe analizar si ésta fue implementada arbitrariamente o por fuera de los parámetros establecidos por las normas aplicables.

Al respecto, nótese primero que la decisión de archivo se fundó en una causal expresamente prevista en la ley, pues ésta autoriza el archivo por oportunidad (art. 211, inc. "e", CPP).

En segundo lugar, el fiscal denunciado *expresó el motivo* por el cual consideraba que correspondía clausurar el caso y, al margen de su acierto o error, el mismo se relaciona con la causal legal indicada sin que pueda catalogárselo como ilegítimo o ilícito. Esto, claro, sin perjuicio de que luego el Fiscal de Cámara interviniente considerase que correspondía disponer el cierre del caso en orden a otra causal — también prevista — en la ley procesal: el inc. "d" del art. 211 CPP.

En otras palabras, aun si nos encontrásemos —eventual e hipotéticamente— ante la existencia de alguna clase de insuficiencia en la actividad instructora desplegada o de equivocación en la clausura del caso —p. ej. su carácter prematuro—, esto no podría alcanzar, en modo alguno, para encuadrar la conducta del acusador en los tipos penales en cuestión, pues, como vimos, la discusión sobre esa clase de actuación procesal defectuosa discurre por las vías impugnativas *normales* de un proceso.

Finalmente, aunque se soslayara lo expresado hasta aquí, tampoco sería viable afirmar que el comportamiento atribuido al fiscal denunciado resultara típico en su faz *subjetiva*. Es que, en el peor de los casos, lo que se le atribuiría es no haber obrado diligentemente en el ejercicio de la facultad de archivar un caso o haber aplicado, culposamente, un criterio errado para ello —p. ej. porque, según el entendimiento del denunciante, hubiere correspondido la previa producción de alguna evidencia— y estas conductas difieren sustancialmente del *dolo directo* que exigen las figuras en trato.

Por lo demás, el archivo dictado no privó definitivamente de algún derecho al denunciante, sino que, por el contrario, le permitió el ejercicio de la facultad que, en su condición de *denunciante* , le es concedida por la ley procesal, esto es, la solicitud de la revisión de esa decisión conclusiva.

Lo afirmado hasta aquí no importa, en modo alguno, soslayar las molestias que las situaciones tal como fueron denunciadas pudieron haber generado en el denunciante, pero lo cierto es que aquellas no reúnen las condiciones necesarias para ser abordadas desde una perspectiva penal.

Por último, cabe hacer saber al nombrado que cuenta con la posibilidad de constituirse como parte querellante con el objeto de continuar de manera autónoma con el ejercicio de la acción

ante el juez, bajo las formalidades de la acción privada (art. 10, CPP), como así también que, según surge del sistema informático Kiwi, el caso MPF 546803 (DEN 713875), caratulado *"HOSPITAL DE AGUDOS PIÑERO S/Art. 292 (1 párrafo)"*, tramitó ante la UIT de la UFO, donde fue archivado por el fiscal interviniente que dispuso: *" Toda vez que la presente denuncia, guarda vinculacio?n con los hechos investigados en el marco del MPF 462972, que tramito? por ante la Fiscali?a Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 20, y siendo que el mismo se encuentra archivado y convalidado dicho archivo por el Fiscal de Ca?mara, entiendo que corresponde estar a lo alli? dispuesto, sin ma?s tra?mite, de conformidad con lo previsto en el art. 211 del Co?digo Procesal Penal de la C.A.B.A".* Esto último, en relación a lo sostenido por el Sr. Kosciuk al momento de formular la denuncia que diera origen a las presentes.

En orden a lo expuesto , atendiendo a las constancias digitales del caso obrantes en el sistema informático *"Kiwi"* (cf. arts. 12, 13 y 14 de la Res. FG nro. 76/2013 y resoluciones subsiguientes) entiendo que corresponde:

NO ACEPTAR LA OPOSICIÓN planteada por el Sr. Kosciuk y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el archivo dispuesto por la UIT de la UFE.

Regístrese y notifíquese al denunciante.

Registro nro. 136/RA/FCEste/2021.

GABRIEL ESTEBAN UNREIN
FISCAL DE CAMARA
gunrein@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
29/03/2021 14:55:29